

1500387-24.2019.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: NAIRA BLANCO MACHADO

Comarca: Arujá

Foro: Foro de Arujá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... - pela inaplicabilidade da lei de crime hediondos a hipóteses de tráfico privilegiado, como o presente caso:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA .1. O tráfico de entorpecentes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Arujá

Foro de Arujá

1ª Vara

Avenida Albino Rodrigues Neves, 394, Aruja - SP - cep 07400-000

1500387-24.2019.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500387-24.2019.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BARBARA VAREJAO DOS SANTOS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). NAIRA BLANCO MACHADO

Vistos.

BÁRBARA VAREJAO DOS SANTOS, qualificada no autos, foi denunciada pela prática do crime descrito no art. 33, caput, c.c. art. 40, III e V, todos da Lei 11.343/06, porque no dia 14 de fevereiro de 2019, na rodovia Presidente Dutra, praça do pedágio, nesta cidade, trazia consigo para fins de tráfico, em ônibus coletivo, e destinado a outro estado da Federação, 04 barras de maconha, contendo 10,6 quilogramas (massa líquida) de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal, para fins de tráfico, droga essa que causa dependência física e psíquica.

Narra a acusação policiais rodoviários federais realizavam fiscalização de rotina na Praça do pedágio e deram ordem de parada a um ônibus da Empresa Transporte Prêmio Turismo. Em vistoria no interior do ônibus os policiais encontraram uma bolsa de cor amarela e preta, no bagageiro superior da poltrona da acusada, na qual estavam as 4 barras de maconha, envoltas em fita adesiva, sendo duas maiores e duas menores. O motorista do ônibus, Gerson, afirmou que viu a acusada ingressar no ônibus com a bolsa e o destino do coletivo era Vitória/ES. A acusada admitiu aos

policiais que a bolsa lhe pertencia, afirmando que a pegou na Rodoviária do Tietê, em São Paulo, de um indivíduo desconhecido e que entregaria a bolsa em Vitória/ES, recebendo para tanto R\$ 1.000,00 pelo transporte da droga.

Auto de Prisão em Flagrante Delito às fls. 01/02. Boletim de Ocorrência às fls.08/10. Auto de exibição e apreensão às fls.11/12. Laudo de constatação (fls.15/16).

Em audiência de custódia (fls. 30/33) foi concedida a liberdade provisória à acusada, fixando-se cautelares diversas da prisão.

Laudo pericial toxicológico definitivo de fls. 59/61. Laudos periciais de fls. 77/84.

Notificada, a ré apresentou defesa preliminar às fls. 132/133.

A denúncia foi recebida em 18/11/2021, às fls. 140/141.

Laudos periciais às fls. 172/182.

Em audiência foram ouvidas testemunhas e interrogada a acusada (fls. 205/209).

O Ministério Público, em alegações finais orais, pugnou pela procedência da denúncia. Quanto à dosimetria, altercou que há possibilidade de reconhecimento de tráfico privilegiado, e sustentou que a ré não apresenta demais anotações em folha de antecedentes, não havendo comprovação de que se dedique à atividades de organização criminosa. Pugnou pela fixação de regime aberto. Afirmou que a ré é genitora de menor de idade, podendo responder em liberdade.

Em alegações finais orais, a defesa da ré afirmou que ela confessou os fatos, devendo ser considerada como "mula". Afirmou que há circunstâncias favoráveis, como ausência de antecedentes e não há personalidade voltada à cometimento de crimes, tratando-se de deslize. Requereu que seja reconhecidas favoráveis as circunstâncias judiciais e do art. 42, da lei de Drogas, sendo aplicada pena no mínimo legal. Afirmou haver incidência da atenuante da confissão. Requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado e fixação de regime inicial aberto.

Os autos vieram conclusos para sentença.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva deve ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade do delito de tráfico de drogas com destino a outro Estado da Federação está demonstrada conforme boletim de ocorrência, laudo de constatação e prova oral colhida.

A autoria delitiva da ré segue a mesma sorte.

Não se comprovou, contudo, que a ré traficava drogas no interior do ônibus de transporte público.

Passo à análise da prova oral colhida no feito:

A testemunha Gerson Prass declarou que era motorista do ônibus e saíram de São Paulo e foram abordados pela polícia Rodoviária no pedágio. Constataram que havia drogas no interior do veículo. Disse que confere as malas quando os passageiros entram no ônibus e não se recorda do rosto da acusada. Afirmou que se recorda do

depoimento da delegacia e disse que a sacola tinha o ticket, a identificação da passagem, constando como da ré.

A testemunha Carlos Eduardo Lopez Montez declarou que estavam fazendo fiscalização na praça de pedágio, com cães, e abordaram o ônibus coletivo que ia para Vitória, saindo de São Paulo. No ônibus entrevistaram passageiros e olhavam bagagens. Na poltrona da ré, em cima do bagageiro superior, havia uma bolsa. Inicialmente a ré disse que não era dela. abriram a bolsa que era preta e amarela e nela havia drogas. Depois entrevistaram a ré e ela se contradizia sobre origem e destino, dizendo que tinha ido na casa da tia, mas não sabia o local ou motivo da viagem. Retiraram a ré do ônibus e ela confirmou, após, que a bolsa era dela, que ela retirou na rodoviária do Tietê, de pessoa desconhecida, entregaria na rodoviária de Vitória/ES, e ganharia um valor de dinheiro por isso. Afirmou que não se recorda de ter conversado com o motorista, por ter muitos casos de pessoas presas em ônibus, mas ratifica o seu depoimento em delegacia.

A testemunha Viviane Higa Kato declarou que se recorda da bolsa que estava acima da poltrona da ré, na qual continha 4 tabletes de maconha. A ré disse que pegou na Rodoviária do Tietê, levaria para a Rodoviária de Vitória e receberia R\$ 1.000,00 para tanto. Afirmou que não se recorda se a ré admitiu que levava a bolsa, depois disse que acredita que desceram com ela do ônibus e ela acabou confirmando que a droga lhe pertencia.

A ré Barbara Varejão Santos declarou em interrogatório judicial que tem 31 anos, trabalha como freelancer com pesquisas e tem renda mensal em torno de R\$ 1.000,00. Afirmou que estudou superior incompleto. É solteira e tem um filho menor de idade. Em relação aos fatos, disse que aceitou essa "oportunidade", por estar precisando de dinheiro. Narrou que o ônibus foi abordado pela polícia e tudo ocorreu como os policiais falaram. Os policiais conversaram com ela da melhor forma. Disse que conheceu uma pessoa em rede social e retirou a bolsa na rodoviária Tietê, e iria entregar em Vitória a um rapaz. Ganharia R\$ 1.000,00 quando entregasse a bolsa. Não tinha conhecimento do conteúdo da mala, mas assim que a abriram a mala soube que tinha droga. Pegou a mala fechada na rodoviária. O rapaz que conheceu fez uma transferência para a compra da passagem de ônibus. Perguntada se na delegacia informou os dados das pessoas que fizeram a proposta, afirmou que ficaram com seu telefone na delegacia. Narrou que não deveria ter aceitado isso, mas naquele momento de desespero acabou aceitando essa "oportunidade" ruim. Atualmente e depois dos fatos nunca mais procurou essa "facilidade".

Essa foi a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A acusada confessou os fatos em interrogatório judicial, confirmando que teria aceitado essa "oportunidade" por estar precisando de dinheiro. Confirmou o que foi dito pelos policiais. Afirmou que pegou a bolsa contendo drogas na rodoviária do Tietê e levaria para Vitória, onde entregaria na Rodoviária e receberia R\$ 1.000,00.

Na bolsa que a acusada trazia consigo, localizada no bagageiro do ônibus e acima de sua poltrona havia 4 tabletes de maconha com peso líquido de 10,6 kg.

Em delegacia a acusada permaneceu em silêncio (fls. 07).

O motorista do ônibus e os policiais rodoviários federais apresentaram relatos de como ocorreu o encontro da droga com a acusada, passageira do ônibus, apresentando os fatos de forma harmônica e como o relatado em delegacia (fls. 03/06).

Ainda, o exame toxicológico confirmou a natureza entorpecente das drogas localizadas (fls. 59/61).

Vê-se, assim, que a prova amealhada durante a instrução processual é suficiente para o reconhecimento do crime de tráfico de drogas pela acusada.

Recorda-se, no mais, que o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06 é de ação múltipla, de modo que se consuma com qualquer das outras condutas descritas no mencionado dispositivo legal, como, transportar, trazer consigo, guardar, ter em depósito, entregar a consumo e fornecer drogas, ainda que gratuitamente.

Nesse mesma toada:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESES DE QUE A PROVA OBTIDA NOS AUTOS É ILÍCITA, E DE QUE O CRIME É IMPOSSÍVEL, POR NÃO TER CHEGADO AO DESTINO, QUE NÃO FORAM VENTILADAS NAS RAZÕES RECURSAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDUTA DE TRANSPORTAR OU TRAZER CONSIGO, COM O INTUITO DE FORNECER, AINDA QUE PARA GRATUITO CONSUMO ALHEIO, QUE SE SUBSUME AO TIPO PREVISTO NO CAPUT DO ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA E CONTEÚDO VARIADO. CONSUMAÇÃO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. [...] 2. "Transportar", "trazer consigo" ou "fornecer ainda que gratuitamente" substância entorpecente ilícita são São Paulo núcleos do tipo do delito de tráfico de drogas - crime de perigo abstrato, de ação múltipla e conteúdo variado, que se consuma com a prática de quaisquer das ações insertas no art. 33 da Lei Antidrogas. (HC 225555/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, j. em 09/12/2012).

Saliento, por oportuno, que o fato de a acusada alegar que não sabia do conteúdo da mala em nada lhe favorece, uma vez que não se mostra crível que uma pessoa concorde em levar uma mala para outro Estado da Federação, a pedido de pessoa que conhece por aplicativo, sem imaginar que algo ilícito possa estar em seu interior.

Nota-se que a ré agiu, no mínimo, com dolo eventual, uma vez que ela confirmou que receberia a quantia de R\$ 1.000,00 para levar a mala até Vitória.

Neste sentido:

Apelação. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Preliminar. Alegação de inépcia da denúncia. Mérito. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários: a) redução do aumento operado na primeira fase; b) aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo. 1. Alegação de inépcia da denúncia. Não acolhimento. Denúncia suficientemente detalhada com descrição pormenorizada das condutas atribuídas aos réus. Indicação do objeto material do tráfico e das circunstâncias de tempo e local. 2. Associação para o tráfico de drogas. Delito não comprovado. Estabilidade e permanência que não se inferem dos elementos coligidos aos autos. Absolvição que se impõe. 3. Tráfico de drogas. 3.1. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais uniformes e convergentes ao longo da persecução penal. Presença de contradições nas versões apresentadas pelos réus, enfraquecendo-os de credibilidade. Conduta dirigida ao comércio espúrio. 3.2. Alegação de desconhecimento quanto ao conteúdo do porta-malas do veículo que conduziam. Versão fantasiosa dos réus que não se sustenta. Apreensão de vultosa quantidade de entorpecente que não poderia passar despercebida. 4. Dosimetria da pena que comporta reparos. 4.1. Aumento desproporcional da pena base. Quantidade de droga excessiva apreendida com os réus. Aumento em razão de uma única circunstância judicial desfavorável. Readequação do aumento operado para o dobro acima do mínimo legal. 4.2. Aplicação da fração e 1/6 (um) sexto em razão do reconhecimento da reincidência do réu Jackson. 5. Do regime inicial para o cumprimento da pena. Fixação do regime fechado. Circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a fixação do regime inicial mais rigoroso. 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJSP; Apelação Criminal 1526141-16.2019.8.26.0228; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 13ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/06/2021; Data de Registro: 16/06/2021) (grifos nossos)

Tratando-se de acusada primária (f.a. fls. 76 e 169/170), deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, pois a ré ostenta

bons antecedentes e inexistente nos autos comprovação suficiente de que se dedique a atividade criminosa.

Incidirá a causa de aumento de estar a acusada transportando drogas a outro estado da federação (art. 40, V, da Lei de Drogas), não incidindo, contudo, a causa de aumento do delito ter ocorrido em ônibus coletivo (art. 40, III, da Lei de Drogas), pelos motivos que serão abaixo explicados.

No mais, inexistente qualquer causa excludente de ilicitude ou que isente o réu de pena, sendo a ação foi culpável, reprovável, pois a ré era (e ainda é) ao tempo da conduta imputável, tendo consciência da ilicitude de suas ações. Não há, portanto, qualquer causa excludente da culpabilidade.

Isto posto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de condenar BÁRBARA VAREJÃO DOS SANTOS, qualificada no autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, c.c.º, e art. 40, inciso V, tudo da Lei 11.343/06.

Apurada a responsabilidade penal, passo a dosar a pena.

Assim, verifico que a ré agiu com a culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar nesse sentido. Não há nos autos elementos concretos que permitam uma valoração da sua personalidade. A ré não ostenta maus antecedentes (fls. 169/170). O motivo do delito se constituiu pela obtenção do lucro fácil, que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito. Nada há, em concreto, que desabone a sua conduta social. As consequências do crime não se mostraram de maior monta. As circunstâncias se revelam desfavoráveis, uma vez que, embora a droga encontrada com a acusada seja de menor poder vulnerante (maconha) quando comparado a outras substâncias entorpecentes, a acusada portava consigo 4 tabletes com peso de 10,6 quilogramas, quantidade significativa da droga. Diante disso, fixo a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 562 dias-multa, no menor valor legal.

Ausentes circunstâncias agravantes.

Incidirá a atenuante da confissão, razão pela qual atenuo a pena da ré, atingindo a pena intermediária o patamar de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 468 dias-multa.

Não é caso de incidência da causa de aumento do art. 40, III, da lei 11.343/06, uma vez que para o reconhecimento desta não basta que a ré traga consigo drogas em transporte público, devendo ocorrer efetivo ato de comércio no interior do ônibus.

Neste sentido:

Apelação. Tráfico de drogas. Recursos das Defesas. 1. Preliminar. Inépcia da denúncia. Não acolhimento. Denúncia suficientemente detalhada com descrição pormenorizada da conduta atribuída aos acusados, bem como circunstâncias de tempo e local. Preliminar rejeitada. 2. Ilícitude probatória decorrente de instauração da persecução com base em denúncias anônimas. Não ocorrência. Muito embora a denúncia anônima não se preste a fundamentar, com exclusividade, as restrições a direitos fundamentais, nada impede possa ela servir de base para a realização de investigações preliminares voltadas à confirmação daquela notícia. A vedação ao anonimato, consagrada pelo texto constitucional, não pode ser lida de forma absoluta a ponto de tornar imprestáveis todas as notícias apócrifas que são levadas ao conhecimento das autoridades policiais. Doutrina. Precedentes do STF. 3. Hipótese fática em que os policiais receberam denúncia anônima indicando que suspeitos transportavam substâncias entorpecentes em um coletivo. Realização de diligência com o fito de confirmar a informação apócrifa. Identificação dos acusados e efetuação da abordagem que resultou na apreensão dos entorpecentes.

Ilegalidade não reconhecida. 4. Mérito. Condenação adequada. Materialidade demonstrada pela apreensão dos entorpecentes e pela prova técnica. Autoria certa. Relatos convergentes dos policiais civis narrando as circunstâncias da prisão em flagrante dos acusados. Confissão judicial de Larissa, Ariadne, Priscila e Vitória. Revelia da apelante Kelly. Versão inconsistente fornecida por Rafael. Destinação comercial comprovada. 5. Dosimetria. Pena-base corretamente fixada acima do patamar mínimo. Quantidade expressiva de drogas. Confissão espontânea reconhecida em favor de Ariadne, Priscila, Larissa e Vitória. Reconhecimento da menoridade relativa em favor de Kelly e Ariadne. 6. Causa de aumento prevista pelo art. 40, inciso III, da Lei de Drogas. Necessidade de afastamento. Para a incidência da majorante é imprescindível a demonstração da efetiva prática da comercialização do entorpecente no interior do veículo de transporte coletivo, não sendo suficiente para a caracterização da causa de aumento a mera utilização do coletivo como meio de locomoção. Precedentes do STJ e do STF. Hipótese fática em que os acusados apenas utilizavam do coletivo para transporte das substâncias. 7. Tráfico privilegiado reconhecido em sentença. Ausência de recurso do Ministério Público que impede a o afastamento sob pena de reformatio in pejus. Exorbitante quantidade de drogas. Redução em 1/5 mantida. Regime fechado mantido. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Multa fixada proporcionalmente. Detração não aplicada. Prisão preventiva mantida. 8. Recursos parcialmente providos. (TJSP; Apelação Criminal 1500051-68.2020.8.26.0540; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Pires - 2ª Vara; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 03/08/2022) - grifos nossos.

Assim, apontando todos os relatos dos autos que a droga estava embalada em interior de bolsa com destino a outra cidade, e não havendo venda no transporte público de entorpecentes, deve ser afastada a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas.

Presente, todavia, a causa de aumento do tráfico interestadual, art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, aumentando a pena em 1/6, passando para 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 546 dias-multa.

Incide, como já asseverado alhures, a causa de diminuição de pena do §4º, art. 33, da Lei 11.343/06, uma vez que a ré é primária, não possuindo antecedentes, não havendo ainda provas suficientes de que se dedique a atividades criminosas ou de que integre organização criminosa, não tendo sido produzida pela acusação nenhuma prova de vínculo aprofundado e estável com o comércio espúrio, para cujo reconhecimento seria necessária a existência de prova cabal neste sentido. Neste ponto, vale mencionar a manifestação de César Dário Mariano:

Presentes os requisitos previstos na norma a diminuição da pena é obrigatória, não ficando ao alvedrio do Juiz operar a redução ou não. Embora a norma empregue a expressão "as penas poderão ser reduzidas", não se trata de atividade discricionária do Juízo, mas de direito subjetivo do acusado. Aliás, a primariedade e bons antecedentes deverão ser demonstrados pelo acusado, ao passo que caberá ao Ministério Público o ônus de provar que o réu se dedica à atividade criminosa ou que pertence à organização criminosa. Não cabe ao réu a prova de fatos negativos, mas a quem alega, no caso, o Ministério Público.

(...) Dedicar-se a atividades criminosas pressupõe reiteração de condutas tipificadas como crime, ou seja, habitualidade no cometimento de delitos. Tal circunstância poderá ser demonstrada por meio de folhas de antecedentes criminais, certidões cartorárias, cópias de outros processos, testemunhas, ou seja, qualquer meio hábil a provar a vida criminosa do acusado. Como a norma não diz qual espécie de atividade criminosa poderá ser qualquer uma, desde que, obviamente, não se trate de delitos culposos, que pressupõem ausência de vontade.

A norma visa a impedir a redução da pena para aquele que de forma habitual e deliberada pratica qualquer espécie de crime. Com efeito, aquele que faz da vida

criminosa seu modo de vida não é merecedor do redutor. (Silva, César Dario Mariano da Lei de drogas comentada / César Dario Mariano da Silva. -- 2. ed. -- São Paulo : APMP - Associação Paulista do Ministério Público, 2016).

Em sentido semelhante:

"A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena" (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50).

Outrossim, conforme explanado anteriormente, a quantidade de drogas, por si só, não pode resultar na interpretação de que a ré faz do tráfico seu meio de vida ou integra organização criminosa. Nesse sentido, em complemento aos arestos já colacionados, seguem os julgados abaixo:

Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA (132,85 KG). DEDICAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE ABSOLVIDA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE.

I - A grande quantidade de entorpecente, apesar de não ter sido o único fundamento utilizado para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, foi, isoladamente, utilizado como elemento para presumir-se a participação da paciente em uma organização criminosa e, assim, negar-lhe o direito à minorante.

II - A quantidade de drogas não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Ausência de fundamentação idônea, apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes.

III - É patente a contradição entre os fundamentos expendidos para absolver a paciente da acusação da prática do delito tipificado pelo art. 35 da Lei 11.343/2006 e aqueles utilizados para negar-lhe o direito à minorante constante do art. 33, § 4º, do mesmo diploma legal. Precedentes.

IV - Recurso ordinário ao qual se dá provimento, em parte, para reconhecer a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, e determinar que o juízo a quo, após definir o patamar de redução, recalcule a pena e proceda ao reexame do regime inicial do cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal. (STF. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 138.715 MATO GROSSO DO SUL.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. SÚMULA 7/STJ. CONTRIBUIÇÃO DO AGENTE COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NA CONDIÇÃO DE MULA. APLICAÇÃO DO REDUTOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Assentado pelo Tribunal a quo, soberano na análise dos fatos, que inexistente prova da dedicação da acusada à atividade criminosa, a alteração desse entendimento enseja o revolvimento do conteúdo probatório dos autos, inadmissível em recurso especial (Súmula 7/STJ). 2. No caso, conforme se extrai dos excertos, o Tribunal de origem, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, concluiu motivadamente pela aplicação do redutor no patamar de 1/3, tendo em vista que a atuação da ré era típica de 'mulas do tráfico', embora tenha sido apreendida com grande quantidade de drogas (33 kg de maconha). 3. O atual entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria é no sentido de que a simples atuação como "mula", por si só, não induz que o réu integre organização criminosa, de forma estável e permanente, não constituindo,

portanto, fundamento idôneo para afastar a aplicação do redutor em sua totalidade, tratando-se de meras ilações, presunções ou conjecturas, até porque pode se tratar de recrutamento único e eventual (Precedentes.) 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1776471 MS 2018/0285250-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AGENTE NA CONDIÇÃO DE "MULA". REDUÇÃO EM 1/3. PROPORCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. 2. Hipótese em que a instância antecedente, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos - 153 kg de cocaína - para elevar a pena-base em 3 anos e 4 meses acima do mínimo legal, o que não se mostra desproporcional. 3. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 4. A ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas é circunstância apta a justificar a redução da pena em 1/3, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Logo, devidamente motivada a escolha do patamar de redução, a alteração desse quantum é questão afeta à atividade discricionária do julgador, que só pode ser revista quando verificada sua desproporcionalidade, o que não é o caso dos autos. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 495680 SP 2019/0058485-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019)

Diante disto, cabível a redução à razão de 2/3, já que somente a quantidade de drogas não é elemento suficiente a afastar a minorante ou mesmo modular a fração do benefício. Demais, a natureza e quantidade da droga já foram consideradas por ocasião da valoração das circunstâncias judiciais.

Nesse sentido, o recente julgado do STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO PERMITEM AFERIR A DEDICAÇÃO DO ACUSADO À ATIVIDADE CRIMINOSA E, PORTANTO, NÃO SE PRESTAM PARA JUSTIFICAR O AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAR A FRAÇÃO DESSE BENEFÍCIO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (RECURSO ESPECIAL Nº 1925096 - SP - RELATORA: MINISTRA LAURITA VAZ - Brasília, 02 de agosto de 2021). (grifos nossos).

Assim, diminuo a pena em 2/3, ficando a ré condenada à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) dias de reclusão cumulada com 182 dias-multa, no mínimo legal, pena esta que torno definitiva.

Nesse contexto, à míngua de outras causas modificadoras, fica a ré BÁRBARA VARJÃO DOS SANTOS, qualificada nos autos, definitivamente condenada por tráfico privilegiado à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) dias de reclusão cumulada com 182 dias-multa, no mínimo legal, pena esta que torno definitiva.

Do regime inicial de cumprimento de pena e alternativas penais

O parágrafo 4^a do art. 33 da lei 11.343/06 de forma louvável, admitiu em casos como o ora analisado, a possibilidade de redução da pena imposta ao acusado primário e de bons antecedentes em até 2/3. A previsão legal de uma causa de diminuição de pena nestas circunstâncias tratou de prestigiar da forma adequada o princípio constitucional da individualização da pena, reconhecendo uma situação fática que salta aos olhos do operador do direito: o de que traficantes eventuais, de bons antecedentes e que nunca se envolveram em organizações criminosas não podem ser equiparados aos grandes comerciantes de drogas, verdadeiros empresários do tráfico, responsáveis por manter toda uma rede articulada de produção e distribuição de drogas, auferindo grandes lucros da atividade e fomentando o cometimento de outros tantos delitos graves. Como se vê, são duas espécies distintas de criminosos a justificar tratamentos diversos pela lei penal.

Estranhamente, o próprio dispositivo legal supra aludido, de forma incongruente, negava expressamente a possibilidade de substituição da pena privativa em pena restritiva de direito, afastando-se, desta feita, dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, e, como tal, do próprio princípio da individualização da pena que, de início, parecia pretender alcançar.

Não há dúvida, como mencionado alhures, que a reprovabilidade da conduta do traficante ocasional é menor do que a dos grandes traficantes de droga responsáveis por coordenar e alimentar a grande cadeia do tráfico ilícito de entorpecentes. Eis a razão pela qual a nova lei de drogas, de forma feliz, reconheceu a culpabilidade atenuada daqueles pequenos criminosos, permitindo uma razoável diminuição da pena que eventualmente lhe venha a ser imposta.

Todavia, a concretização da máxima da individualização da pena não se esgota na dosagem da quantidade de pena aplicada ao réu, mas também se funda na determinação de sua qualidade ou natureza. Se a culpabilidade do réu é de menor grau, sustentando a lei uma diminuição da pena imposta, não subsiste razão jurídica para obstar ao réu a concessão de benefícios penais condizentes com a sua menor culpabilidade.

A substituição da pena privativa por restritiva de direito é mecanismo salutar e consentâneo com os primados do Estado Democrático de Direito em que vivemos, sendo, em caso como ora apresentado, bastante a demonstrar a reprovação do Estado com relação à conduta perpetrada pela agente, evitando-se assim os males que o sistema carcerário acarreta, mormente no tocante a presos que cometeram pequenos delitos, como a ora acusada.

A vedação outrora inserta no art. 33, §4º da lei 11.343/06 que impedia a substituição da pena privativa imposta revelava-se incoerente e arbitrária, destoando dos preceitos constitucionais aos quais deve estar atrelada, motivo pelo qual deveria ter sua aplicação afastada. Aliás, tal providência é hoje desnecessária, uma vez que o Senado Federal, desde 16.02.2012, seguindo a linha da jurisprudência dos tribunais, resolveu por bem baixar a resolução nº 05/2012, suspendendo a expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” constante do § 4º do art. 33 da lei 11.343/06, de modo que desde tal data, não subsiste mais qualquer empecilho legal à substituição da pena nos casos de tráfico privilegiado.

Também afastada deve ser a regra inserta no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, por determinar o cumprimento inicial da pena imposta por tráfico de entorpecentes, sempre no regime fechado, pelas mesmas razões declinadas relativas ao dispositivo que vedava a substituição da pena.

Aliás, o próprio STF, já vem entendendo - além da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito - pela inaplicabilidade da

lei de crime hediondos a hipóteses de tráfico privilegiado, como o presente caso:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO:

INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA .1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida. (HC 118533, Relator(a): Min. CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 16-09-2016 PUBLIC 19-09-2016

PENA REGIME FECHADO INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1º, § 1º, DA LEI Nº 8.072/1990. A imposição do regime inicial fechado, prevista na Lei de Crimes Hediondos, é inconstitucional, considerado o princípio da individualização da pena. Precedente: habeas corpus nº 111.840, relator o ministro Dias Toffoli, julgado pelo Pleno em 27 de junho de 2012, acórdão publicado no Diário da Justiça de 17 de dezembro de 2013. PENA TRÁFICO DE DROGAS SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DA LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 44 DA LEI Nº 11.343/2006. A vedação à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, prevista na Lei de Tóxicos, é inconstitucional, ante o princípio da individualização da pena. Precedente: habeas corpus nº 97.256, relator o ministro Carlos Ayres Britto, julgado em 1º de setembro de 2010 pelo Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 16 de dezembro imediato. PENA EXECUÇÃO REGIME DE CUMPRIMENTO. Não se tratando de réu reincidente, ficando a pena no patamar de 2 anos e sendo as circunstâncias judiciais positivas, cumpre observar o regime aberto e apreciar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos artigos 33 e 44 do Código Penal. (HC 129714, Relator(a):& Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 25-04-2017 PUBLIC 26-04-2017) (grifos nossos)

Esse mesmo entendimento vem sendo seguido pelo STJ, senão vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. LEGALIDADE. RECENTE ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS E OBJETIVAS QUE RECOMENDAM A REDUÇÃO MÁXIMA. REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO. PACIENTE PRIMÁRIA, CONDENADA À PENA QUE NÃO EXCEDE 4 ANOS, COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, entendeu que a possibilidade de início da execução da pena condenatória após a confirmação da sentença em segundo grau não ofende o princípio constitucional da presunção da inocência (HC n.126292, julgado no dia 17 de fevereiro de 2016). 3. No caso, a jurisdição das instâncias ordinárias encontra-se encerrada, porquanto na

fase de admissibilidade do recurso especial interposto pelo paciente, sendo possível dar início à execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, sem que isso importe em violação do princípio constitucional da presunção de inocência.4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.5. No caso, verifico que a quantidade de entorpecentes não é expressiva para aplicar a fração em patamar diverso do máximo, com relevo para o fato de que a paciente era menor de 21 anos na data do fato, é primária, está grávida e já está inserida no mercado de trabalho. Assim, o redutor comporta aplicação em seu patamar máximo.6. Em relação ao regime, cumpre asseverar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/1990, com a redação dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, determinando, também nesses casos, a observância do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, c/c o art. 59, do Código Penal.7. No caso, o regime fechado, mais severo do que a pena comporta, foi fixado com base na hediondez do delito e na gravidade abstrata da conduta, fundamentos que não são considerados idôneos para fixar o regime mais gravoso. 8. Dessa forma, tratando-se de ré primária, condenada à pena privativa de liberdade não superior a 4 anos de reclusão, com a análise favorável das circunstâncias judiciais, a paciente faz jus ao regime aberto, a teor do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, assim como resulta cabível a conversão da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos.9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para restabelecer a sentença. (HC 391.679/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DAFONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017)

Com efeito, seguindo a linha do que vem sendo sustentado pelos tribunais superiores, é, de fato, inevitável o reconhecimento da invalidade da norma proibitiva do início de cumprimento da pena em regime diverso do fechado pela violação ao devido processo legislativo, por não observar os comandos constitucionais de individualização da pena, porque, embora tenha cominado para o mesmo crime penas diversas em razão das condições pessoais dos acusados, com reconhecimento do excesso de penas ao primário, exige-lhe igual recolhimento ao cárcere, em regime fechado, a afrontar também o princípio da proporcionalidade. Nessa esteira, insta observar que o próprio Ministério Público pugnou pela fixação de regime diverso do fechado em suas alegações finais.

Com essa convicção, resultante da interpretação da norma infraconstitucional ao influxo da Constituição da República, embora haja uma circunstância judicial desfavorável, o regime inicial será o ABERTO, conforme determina o art. 33, e parágrafos, do Código Penal. Saliento que o regime inicial deve ser adequado à quantidade da pena, que no presente caso permite o estabelecimento do regime aberto, porque a acusada não é delinquente contumaz, como pode ser inferido das provas acostadas e folha de antecedentes.

A acusada respondeu solta ao processo e portanto, deixo de aplicar o disposto no §2º, do art. 387, do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei nº 12736/12, uma vez que mesmo considerado o tempo em que permaneceu custodiada, não haveria alteração do regime inicial do cumprimento de pena.

Atendidas as condições previstas art. 44, e incisos e art. 77, "caput", inc. III, do Código Penal, com os fundamentos antes apontados, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo prazo da pena original, a

ser especificada em sede de execução penal. Sendo a pena privativa de liberdade superior a um ano, aplico também a pena restritiva de direito consistente na prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo a entidades públicas ou privadas, a ser especificada pelo juízo de Execução, sem prejuízo do pagamento dos dias-multa já fixados.

Direito de recorrer em liberdade

Concedo à ré o direito de apelar em liberdade, tendo em vista a pena aplicada, o regime imposto, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a serem aferidos para as medidas cautelares e a ausência de requisitos para a segregação cautelar.

Disposições Gerais

Com fundamento no art. 58, § 1º, da Lei nº 11.343/06, inexistente controvérsia acerca da qualidade e quantidade da droga, autorizo a incineração, preservada pequena porção para eventual contraprova, com comunicação à Autoridade Policial.

Após o trânsito em julgado da presente decisão condenatória, sendo mantida, determino:

- a) Lançamento do nome da condenada no Rol dos Culpados.
- b) Apuração dos valores das penas de multa aplicada à sentenciada.
- c) Comunicação à Justiça Eleitoral que a sentenciada encontra-se com seus direitos políticos suspensos, face ao disposto no artigo 15, III, da Constituição Federal.
- d) Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno a ré a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atento aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita, nos termos do artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.
- e) Se for o caso, expeça-se certidão de honorários advocatícios ao(s) Defensor(es) nomeado(s) no grau previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.
- f) Com fundamento no art. 58, § 1º, da Lei nº 11.343/06, inexistente controvérsia acerca da qualidade e quantidade da droga, autorizo a incineração, preservada pequena porção para eventual contraprova, com comunicação à Autoridade Policial.
- g) Havendo bens ou valores apreendidos, decorridos 90 dias do trânsito em julgado sem que o proprietário manifeste interesse na sua restituição, fica autorizada a alienação e destinação do produto ao Funad ou Funpen, conforme o caso, a destruição (reciclagem ecológica) dos bens de baixo valor ou em estado que não permita a sua venda, no caso de quantias em dinheiro, não havendo requerimento de levantamento no prazo de 90 dias, decreto a perda da integralidade do valor, tudo conforme disposto nos artigos 118 e seguintes do Código de Processo Penal, dos artigos 516 e seguintes das NSCGJ e ainda do disposto no Manual de Bens Apreendidos do CNJ.

P.I.C.

Aruja, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA